

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Conceito de Crime

Essa aula é muito especial.

Vamos estudar o CONCEITO DE CRIME.

A diferença entre CRIME e CONTRAVENÇÃO PENAL; a diferença entre CRIME FORMAL e MATERIAL; e, por fim, o crime em seu conceito ANALÍTICO.

No estudo do CONCEITO ANALÍTICO de crime estudaremos de modo geral os elementos que formam o conceito de crime.

Com essa visão geral você já estará apto a avançar na matéria. De qualquer forma, é importante você saber que alguns temas que serão tratados nessa aula, também serão objeto de aulas próprias (mais aprofundadas).

Vamos lá.

1. INFRAÇÃO PENAL: CRIME E CONTRAVENÇÃO PENAL

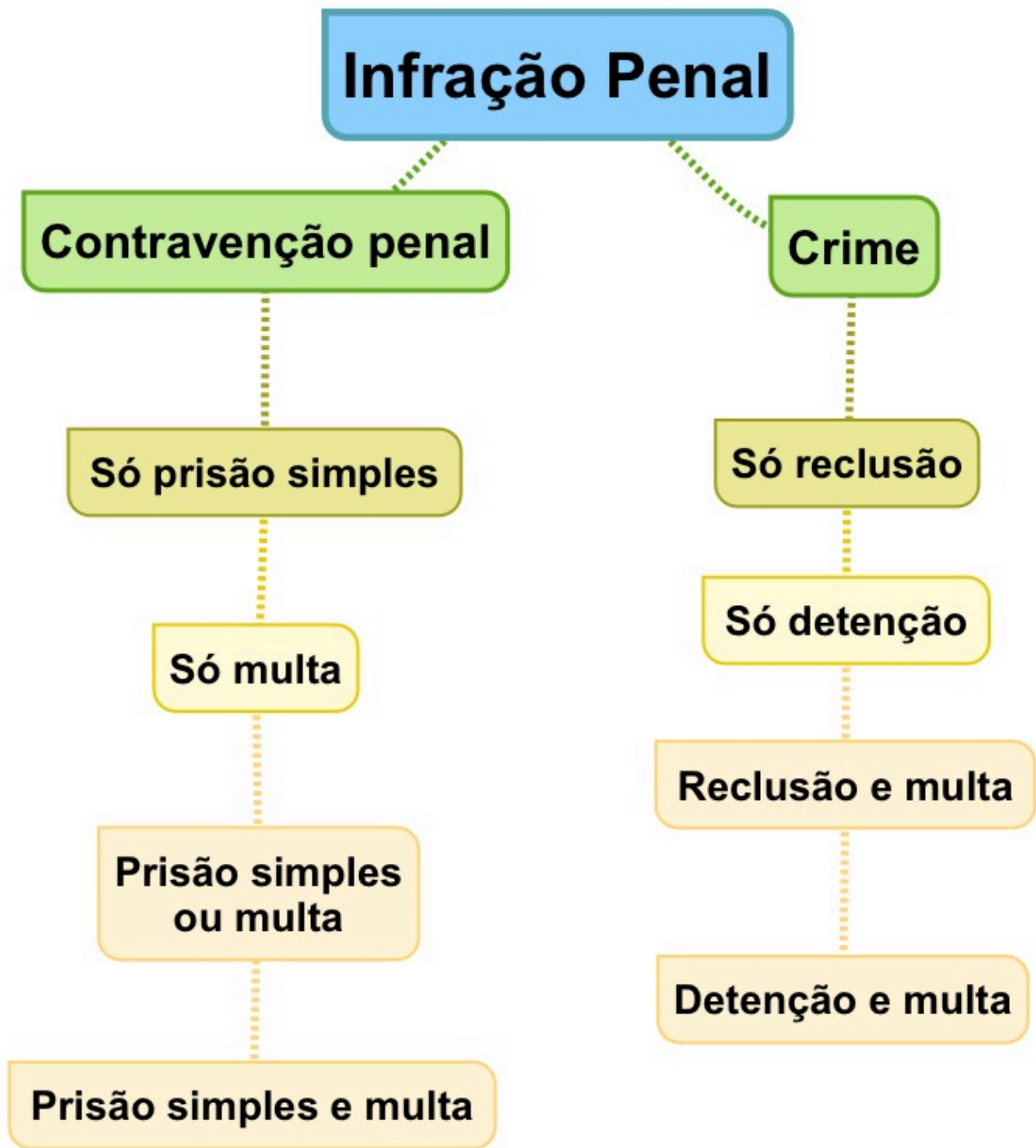
A Lei de Introdução ao Código Penal define o que é crime e o que é contravenção penal:

*Art 1º Considera-se **crime** a infração penal que **a lei comina pena de reclusão ou de detenção**, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa; **contravenção**, a infração penal a que a lei comina, **isoladamente, pena de prisão simples ou de multa**, ou ambas, alternativa ou cumulativamente.*

Assim, INFRAÇÃO PENAL é um gênero de duas espécies: CRIME (reclusão ou detenção) e CONTRAVENÇÃO PENAL (prisão simples ou multa). Essa divisão da infração em duas espécies é conhecida como **sistema dicotômico**.

Preste atenção em relação a MULTA: se ela vier acompanhada de pena de reclusão ou detenção será CRIME. Agora será CONTRAVENÇÃO se a multa for a única pena (isoladamente) prevista para a infração penal, ou ainda, se a previsão for de multa e prisão simples (cumulativamente ou alternativamente).

Vamos resumir:



Até aqui tudo bem!!!

Agora vamos à polêmica!!

A **Lei n. 11.343/2006** não pune o usuário com essas penas (reclusão, detenção, prisão simples ou multa), e sim com algumas penas alternativas:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: I - advertência sobre os efeitos das drogas; II - prestação de serviços à comunidade; III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

E agora: Como fica a situação do “**USO DE DROGAS**”? É crime? É contravenção? Nenhum dos dois?

Por muitos anos, prevaleceu nos tribunais superiores a ideia de que o art. 28 continua sendo crime, mas sem pena de prisão (ou seja, teria ocorrido despenalização, e não descriminalização/abolitio criminis).

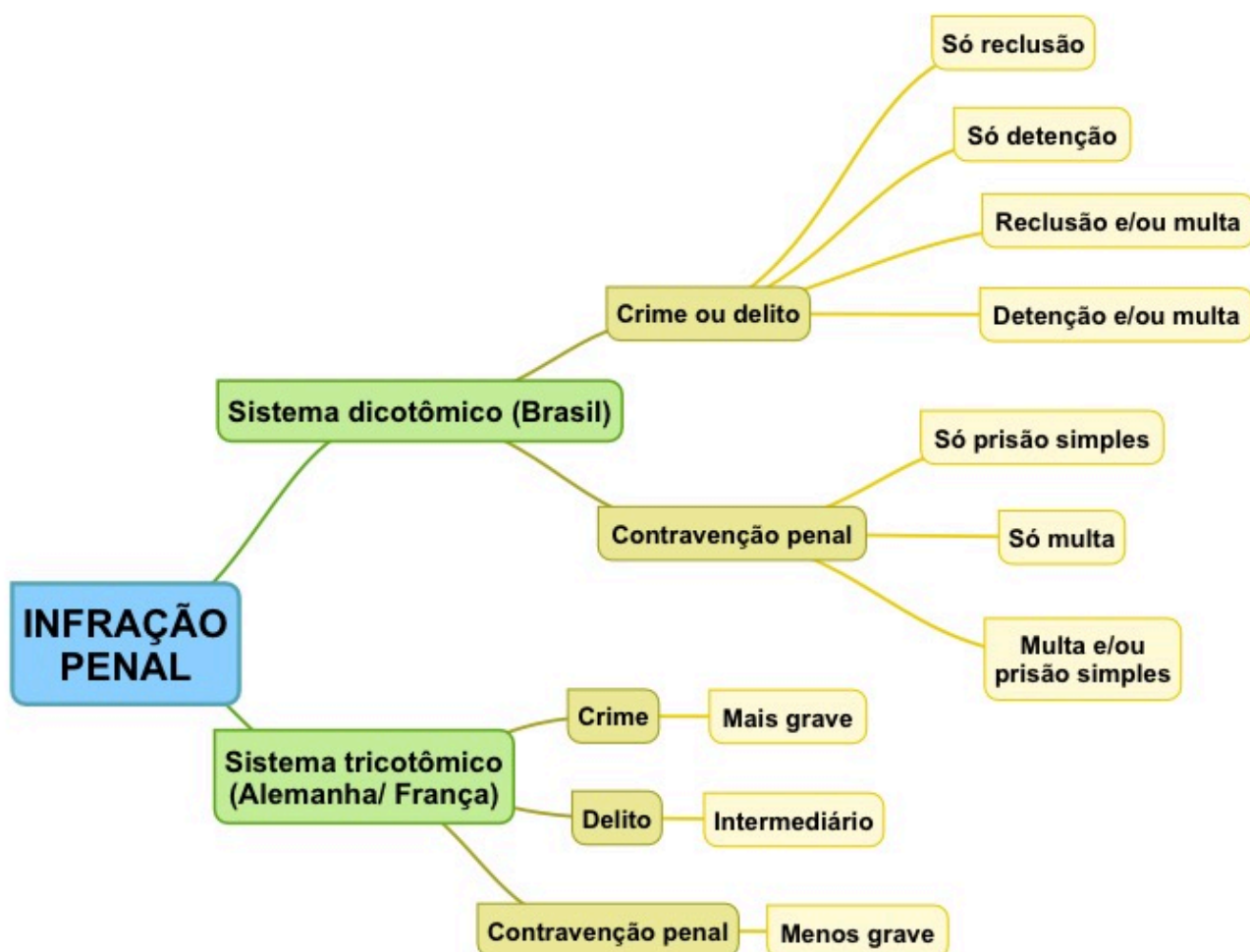
No julgamento concluído em 2024 (Tema 506 - RE 635.659), o STF firmou que o porte de maconha para uso pessoal não é crime, devendo ser tratado como infração administrativa, sem consequências penais (por exemplo, sem anotação de antecedentes criminais por isso).

O STF também fixou um critério objetivo de referência para diferenciar usuário e traficante, indicando 40 gramas (ou 6 plantas fêmeas) como parâmetro — com ressalvas de que a análise do caso concreto pode afastar o enquadramento automático.

Para as demais substâncias, a jurisprudência anterior (especialmente no STJ) era — e em muitas provas ainda é cobrada como — a de que o art. 28 configura crime despenalizado (não houve “liberação”, e tampouco legalização).

Por fim, é importante você saber em que alguns países (Alemanha, França) a INFRAÇÃO PENAL é dividida em 3 ESPÉCIES (sistema tricotômico): CRIMES (mais graves); DELITOS (gravidade intermediária) e CONTRAVENÇÕES PENAS (menos graves). No Brasil (sistema dicotômico), DELITO é a mesma coisa que CRIME.

Vamos recapitular:



2. CONCEITO MATERIAL E FORMAL DE CRIME

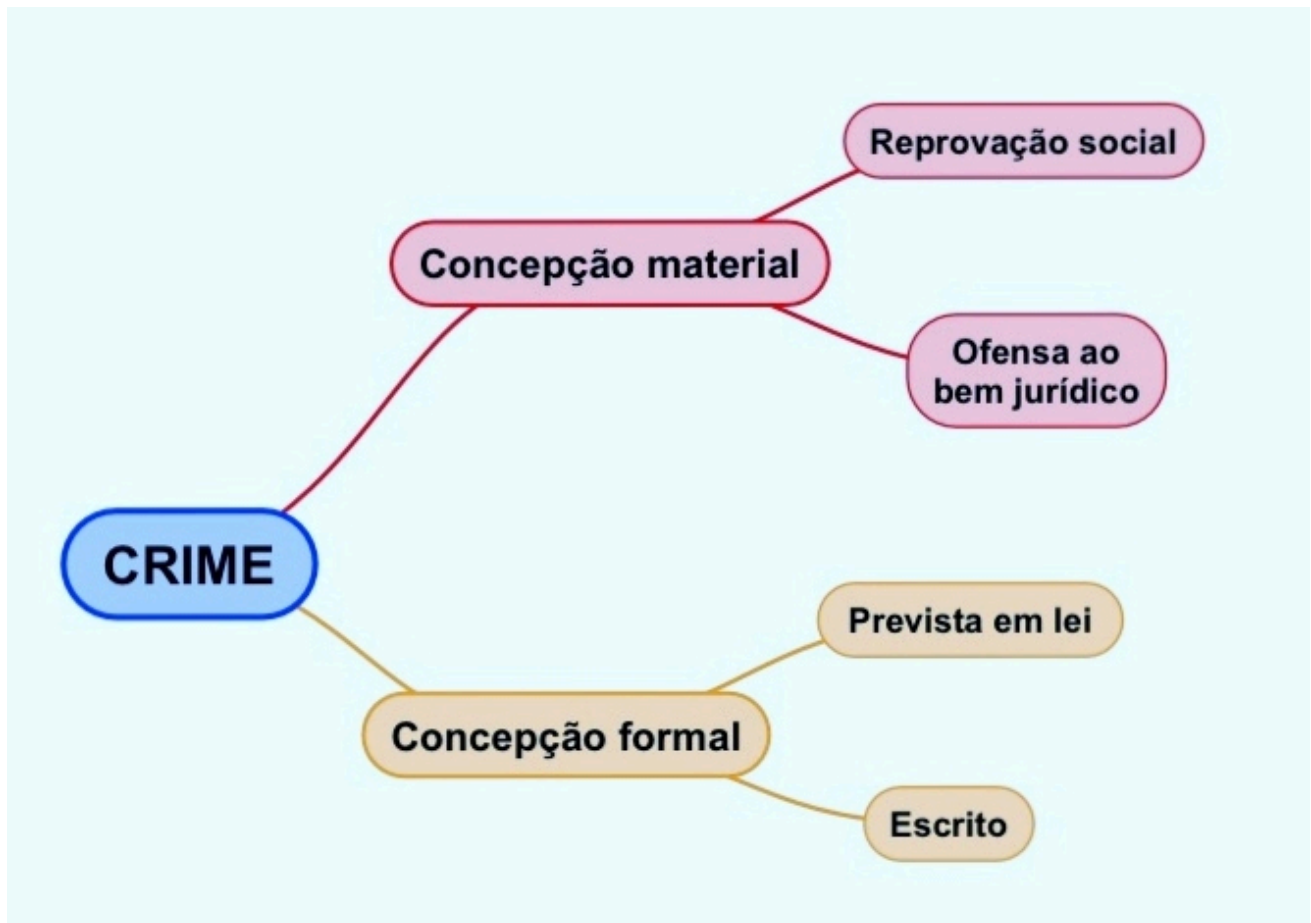
Sabe quando você vê determinado acontecimento e pensa: *Isso é um CRIME!!*

A concepção MATERIAL de crime é justamente essa. O conceito MATERIAL de crime é aquele que nasce do SENTIMENTO da sociedade. Seria o que OFENDE um BEM JURÍDICO.

O conceito MATERIAL serve de guia para a FORMALIZAÇÃO de um crime. Em outras palavras, o legislador filtra esse sentimento de reprovação, e FORMALIZA, por meio de uma LEI, o que será FORMALMENTE considerado um CRIME.

Portanto, crime na concepção FORMAL é a conduta prevista em lei como proibida e que caso violada implicará em uma punição.

Resumindo:



Esse assunto pode parecer um pouco teórico, mas é muito atual e importante. Tanto é importante que serve para aprendermos dois PRINCÍPIOS ATUALÍSSIMOS do Direito Penal: o princípio da insignificância e o princípio da fragmentariedade.

As teorias mais recentes do Direito Penal exigem **lesividade** ao bem jurídico protegido pela lei penal. Em outras palavras, só há crime se houver lesão ao que se protege. É o famoso e tão falado **PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA**.

Grosso modo, devemos entender que um crime deve ter uma FORMA, que é aquilo que está ESCRITO na Lei Penal, é o conceito FORMAL do crime. É um conceito frio e legalista.

Por outro lado, o crime também deve ter um caráter MATERIAL, ou seja, UMA CONSEQUÊNCIA NO MUNDO MATERIAL, NO MUNDO REAL.

Não basta violar o que está ESCRITO na lei (a concepção formal – Tipicidade Formal), a conduta deve ter SIGNIFICANTE consequência no mundo material (a concepção material - Tipicidade Material).

Assim, o Judiciário vem entendendo, que em alguns casos, a lesão ao bem jurídico protegido (tutelado) é tão pequena, tão INSIGNIFICANTE, que não haverá crime, **que não haverá TIPICIDADE MATERIAL**, por mais que haja **tipicidade formal** (o fato se encaixe perfeitamente na lei incriminadora - tipo penal).

Exemplificando: a mãe que furta um litro de leite do supermercado para dar ao filho. Ela realmente cometeu formalmente um furto, ou seja, a conduta dessa mãe é perfeitamente enquadrada no tipo penal do furto. Entretanto, a lesão ao bem jurídico é tão pequena, tão insignificante, que não haverá crime, pois entende-se que não houve lesão ao bem tutelado (não houve lesão ao patrimônio), não houve tipicidade material.

O princípio não é aplicável a qualquer caso. Para se aferir a insignificância de uma conduta, o aplicador do direito leva em consideração vários elementos, veja a decisão do Supremo Tribunal Federal:

*Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, **a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada** - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público (Processo: HC 84412 SP; Relator(a): CELSO DE MELLO; 19/10/2004)*

Beleza! Viu como a concepção material e formal de crime tem tudo a ver com o princípio da insignificância? Então, há a mesma ligação com o princípio da fragmentariedade.

O princípio da fragmentariedade é dirigido ao legislador penal, ou seja, a quem vai criar os crimes.

Pensem assim: *o que a lei pode considerar crime? Qualquer tipo de conduta? A lei poderia considerar crime “usar boné”?*

Não. O princípio da FRAGMENTARIEDADE de TODAS as condutas existentes, só **PARTE** DE TODAS AS CONDUTAS podem ser consideradas crimes. SÓ **FRAGMENTOS** DE TODAS AS CONDUTAS podem ser consideradas crimes.

Só as condutas mais gravosas, perigosas, reprováveis, intoleráveis, **SÓ AS CONDUTAS MATERIALMENTE CRIMINOSAS**.

Em outras palavras, o Direito Penal não se preocupa com todas as condutas sociais, mas só com ALGUMAS (FRAGMENTOS) condutas, as reprováveis.

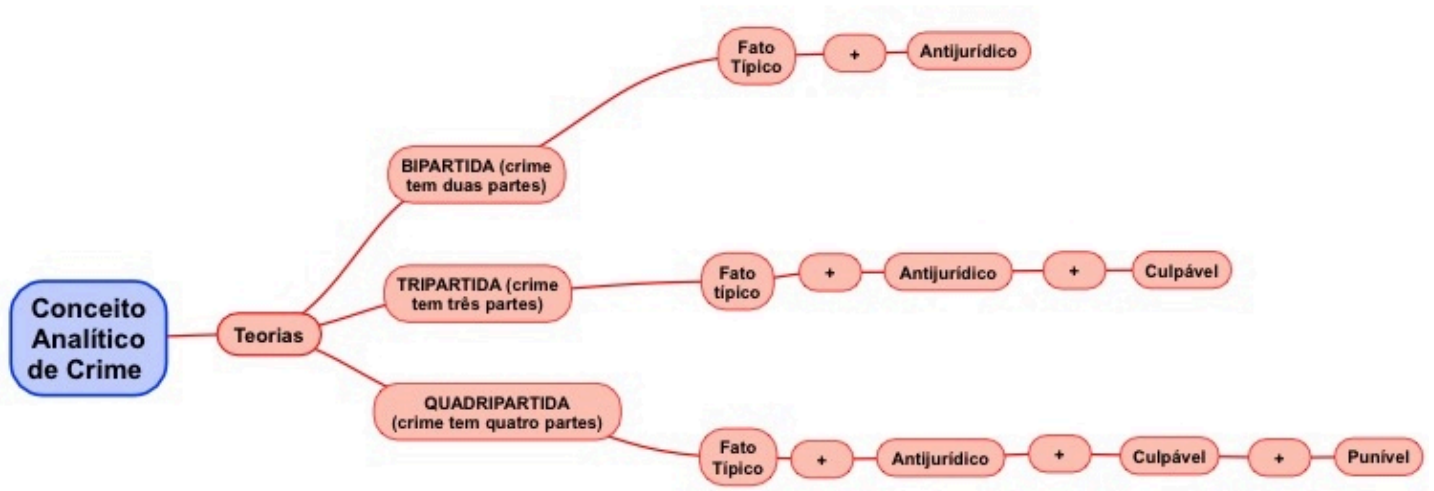
Agora que entendemos o CONCEITO FORMAL e MATERIAL de CRIME, podemos destrinchar o CRIME, ou seja, ver como um crime é formado, parte por parte, elemento por elemento, e quem faz isso é conceito analítico (de análise) de crime.

3. CONCEITO ANALÍTICO DE CRIME

O conceito ANALÍTICO ou FRAGMENTADO de crime busca estudar/indicar quais ELEMENTOS (fragmentos) devem estar presentes para que determinada conduta seja considerada CRIME.

Grosso modo, CRIME será uma soma de várias PARTES. Uma espécie de quebra-cabeça, que para ser formado (caracterizado) deveria reunir todas as peças (todas as partes, todos os elementos).

A doutrina diverge quanto aos elementos (as partes, as peças) necessários para configuração de um crime. As teorias são muitas. Divergem conforme o número de PARTES (elementos) de um crime e quais são essas PARTES de um crime. Vamos apresentar os mais importantes nessa forma esquematizada:



Por ser tão pouco reconhecida, nem vou explorar a teoria quadripartida (é importante só você saber que existe).

Por outro lado, é muito importante você entender a diferença entre as teorias bipartida e tripartida.

Fica mais fácil entender por meio de um exemplo.

Mario “rouba” a namorada de José (16 anos). Por vingança, José (16 anos) mata Mario com três tiros.

A conduta de José é um FATO TÍPICO? Sim, pois se enquadra no crime de homicídio (CP, Art. 121 - “matar alguém”).

A conduta de José é ANTIJURÍDICA? Sim, pois é contrário ao direito, em outras palavras, não há lei que permita José matar Mario (diferente seria se José estivesse em legítima defesa, por exemplo).

Para teoria Bipartida já estaria configurado o CRIME (fato típico + antijurídico).

Agora te pergunto, José tem 16 anos, ou seja, é menor de idade. Sabendo que no Brasil quem tem menos de 18 anos não é considerado culpável. Ainda assim, sua conduta será crime?

Aqui está a diferença entre as duas teorias.

Pela teoria bipartida (que não considera a culpabilidade elemento do crime) será considerado crime mesmo que menor de idade (mesmo que não culpável). José (menor de idade) cometeria um CRIME, mas esse crime não seria considerado culpável, logo, não haveria pena. Por isso, que a doutrina bipartida diz a culpabilidade é apenas um pressuposto (uma condição) da pena. A teoria bipartida é adotada pela doutrina tradicional.

Pela teoria Tripartida (que considera a culpabilidade elemento do crime) não haverá crime, visto que José é menor de idade. José não é culpável e, como a culpabilidade é necessária para configuração de um crime, José sequer teria cometido um crime. Essa teoria vem sendo adotada modernamente. Adotaremos a teoria tripartida para explorar cada elemento do crime.

4 PARA SER CRIME O FATO DEVE SER TÍPICO

Ninguém comete um crime em PENSAMENTO. Pensar em fazer algo não é crime. Em outras palavras, a COGITAÇÃO não é crime.

O crime exige uma **CONDUTA: uma AÇÃO ou uma OMISSÃO**.

Na **AÇÃO** indica-se um FAZER, ou seja, o agente tem que AGIR. É um ato também conhecido como COMISSIVO. Entretanto, não é toda ação que implicará em um crime, e sim a **ação DOLOSA ou CULPOSA**. Ressalta-se que há dois tipos de crimes **OMISSIVOS: os PRÓPRIOS e os IMPRÓPRIOS**.

Pois bem, cogitação não é crime, para ser crime, para ser um fato típico, exige-se uma CONDUTA (ação/omissão). No entanto, só a CONDUTA não basta. Essa CONDUTA para ser TÍPICA exige outro elemento: a **TIPICIDADE**.

Grosso modo, tipicidade é o enquadramento do fato à lei incriminadora. Já vimos isso no começo da aula.

Mario “rouba” a namorada de José (16 anos). Por vingança, José (16 anos) mata Mario com três tiros.

Há TIPICIDADE? Sim, pois se enquadra perfeitamente no crime de homicídio (CP, Art. 121 - “matar alguém”).

Além disso, vimos que modernamente exige-se a TIPICIDADE MATERIAL, ou seja, que a conduta OFENDA de modo SIGNIFICATIVO o bem jurídico protegido.

Vou resumir para você não se perder.

Um dos elementos do CRIME é o FATO TÍPICO e até agora vimos que para o FATO ser TÍPICO exige-se a CONDUTA (omissão ou ação) e a TIPICIDADE (o enquadramento legal).

Os outros dois ELEMENTOS DO FATO TÍPICO são o RESULTADO e o NEXO CAUSAL.

A doutrina elenca dois tipos de RESULTADO: o RESULTADO JURÍDICO e o RESULTADO NATURALÍSTICO.

Se considerarmos o RESULTADO JURÍDICO, que seria qualquer consequência no mundo jurídico. Em TODOS CRIMES o FATO TÍPICO seria composto de CONDUTA, TIPICIDADE, RESULTADO JURÍDICO e NEXO DE CAUSALIDADE.

No entanto, se considerarmos o RESULTADO NATURALÍSTICO a situação seria outra. Nesse caso, no caso de CRIMES FORMAIS e de MERA CONDUTA a CONDUTA e a TIPICIDADE já bastam para configurar um FATO TÍPICO, visto que são crimes que se configuram independentemente de um resultado no mundo exterior.

Por exemplo, quando um funcionário público SOLICITA uma VANTAGEM INDEVIDA poderá estar cometendo o crime de CORRUPÇÃO PASSIVA. O fato de receber ou não a vantagem SOLICITADA, **não interfere na consumação do delito**. A doutrina classifica esse tipo de crime como FORMAL. É considerado formal porque não exige que “materialmente” ocorra algo para se consumir. Assim, na corrupção passiva, basta a SOLICITAÇÃO da vantagem, se SOLICITOU já está consumado o crime. Não há necessidade de RESULTADO NATURALÍSTICO, ou seja, não é necessário que o funcionário público RECEBA a VANTAGEM INDEVIDA. São crimes formais também os crimes omissivos próprio. Uma omissão de socorro, por exemplo, não há necessidade de ocorra alguma coisa com a pessoa “não socorrida”, basta omitir o socorro para configurar o crime.

Se fosse necessária a ocorrência “material” de algo, teríamos um crime MATERIAL. Nesses crimes há exigência do RESULTADO NATURALÍSTICO, uma mudança no MUNDO REAL. Grosso modo, exige que da CONDUTA resulte uma CONSEQUÊNCIA. Esses crimes são chamados de MATERIAL e a configuração do FATO TÍPICO exige os seguintes elementos: CONDUTA, TIPICIDADE, **RESULTADO NATURALÍSTICO** e **NEXO CAUSAL**.

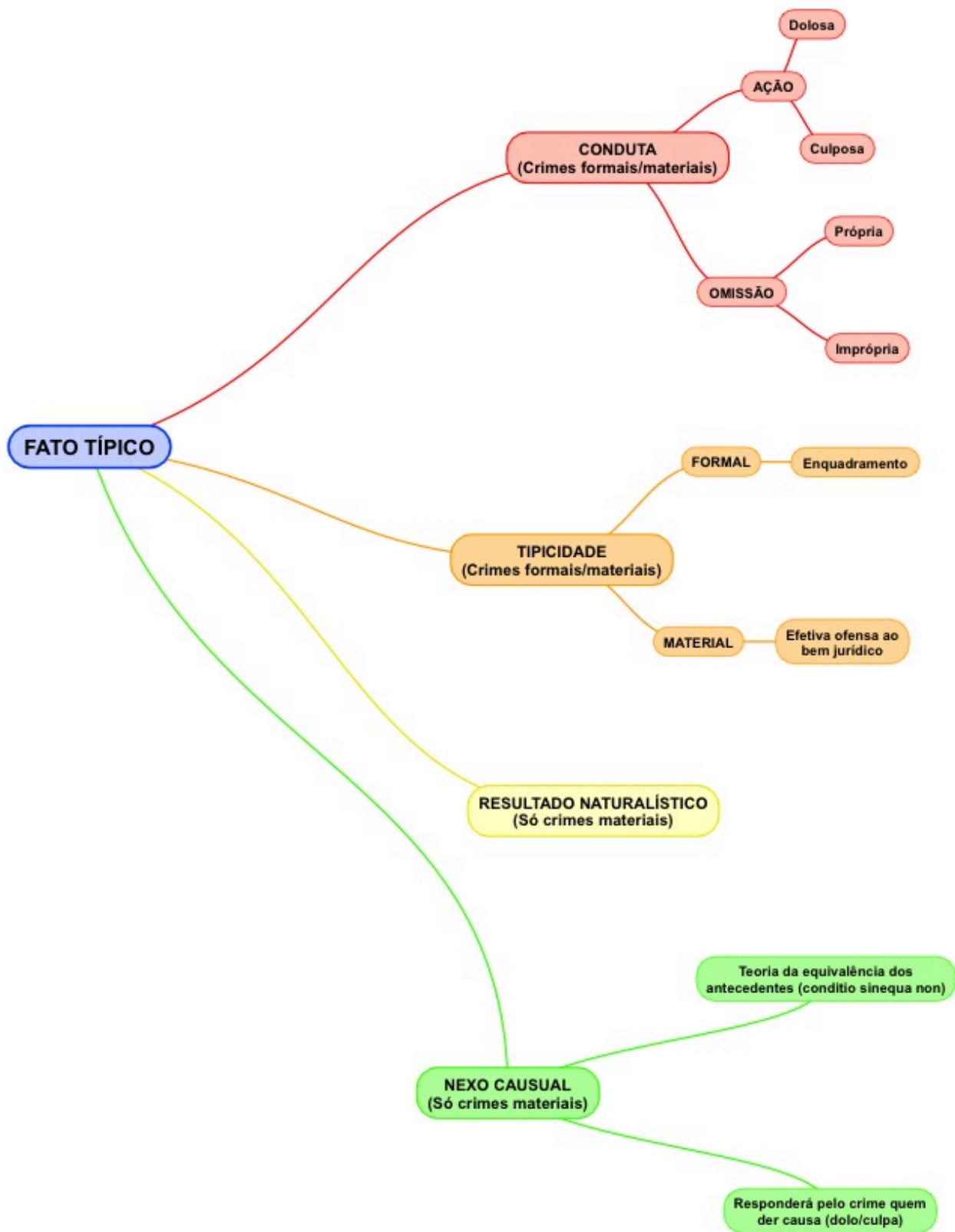
Em suma, RESULTADO NATURALÍSTICO é isso que expliquei, uma mudança no mundo real. A consequência que ocorre em razão da conduta.

Já o Nexo Causal (Relação de Causalidade, Nexa de Causalidade) é a vinculação entre a CONDUTA e o RESULTADO.

Quanto ao nexa causal é importante você saber que o Código Penal adotou a teoria da equivalência dos antecedentes ou da *conditio sine qua non*, assim materializada:

Relação de causalidade Art. 13 - O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido.

A morte de alguém (o resultado) só pode ser imputável a quem lhe deu causa. Em outras palavras, só responderá pela morte (resultado) a pessoa que deu causa por ação/omissão.



5 PARA SER CRIME O FATO TÍPICO DEVE SER ANTIJURÍDICO

Um FATO TÍPICO é ANTIJURÍDICO (ILÍCITO) se for contrário ao direito.

Isso quer dizer que há hipóteses de um FATO TÍPICO não ser crime. Por exemplo, você pode matar alguém sem cometer homicídio.

Como?

Se estiver amparado por uma EXCLUDENTE DE ILICITUDE (Excludente de Antijuridicidade). Veja o que diz o Código Penal:

Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato: I - em estado de necessidade; II - em legítima defesa; III - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Parágrafo único - O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposos.

Nesses casos, se a EXCLUDENTE DE ILICITUDE for adotada sem excessos, a **conduta não será crime criminosa**. A CONDUTA é JURÍDICA, a CONDUTA está CONFORME, DE ACORDO, com o DIREITO. Assim, para ser CRIME exige-se que o FATO TÍPICO seja também **ANTI JURÍDICO**.

Teremos uma aula específica detalhando cada EXCLUDENTE DE ILICITUDE.

6 PARA SER CRIME O FATO TÍPICO ILÍCITO DEVE SER CULPÁVEL (teoria tripartida)

Pela teoria Tripartida (que considera a culpabilidade elemento do crime) não haverá crime se a conduta não for CULPÁVEL.

A culpabilidade está ligada à ideia de REPROVAÇÃO da conduta.

Há culpabilidade quando a conduta praticada for REPROVÁVEL.

Causas excludentes de culpabilidade são hipóteses em que a conduta praticada é TÍPICA, é ANTI JURÍDICA, porém, NÃO É CULPÁVEL, não é reprovável.

Também teremos uma aula detalhada sobre o assunto, mas cabe agora apenas termos algumas ideias básicas.

Basicamente não haverá culpabilidade quando o agente **não for imputável**, visto que o agente não era capaz de entender a ilicitude de sua conduta. É o caso da menoridade, do desenvolvimento mental incompleto ou retardado e embriaguez acidental.

Art. 27 - Os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Art. 26 - É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Art. 28 (...) § 1º - É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Também não haverá culpabilidade se o agente **não tiver CONSCIÊNCIA da ILICITUDE da conduta (Erro de Proibição Inevitável)**. O Código Penal entende que por não haver consciência da ilicitude, a conduta não é reprovável:

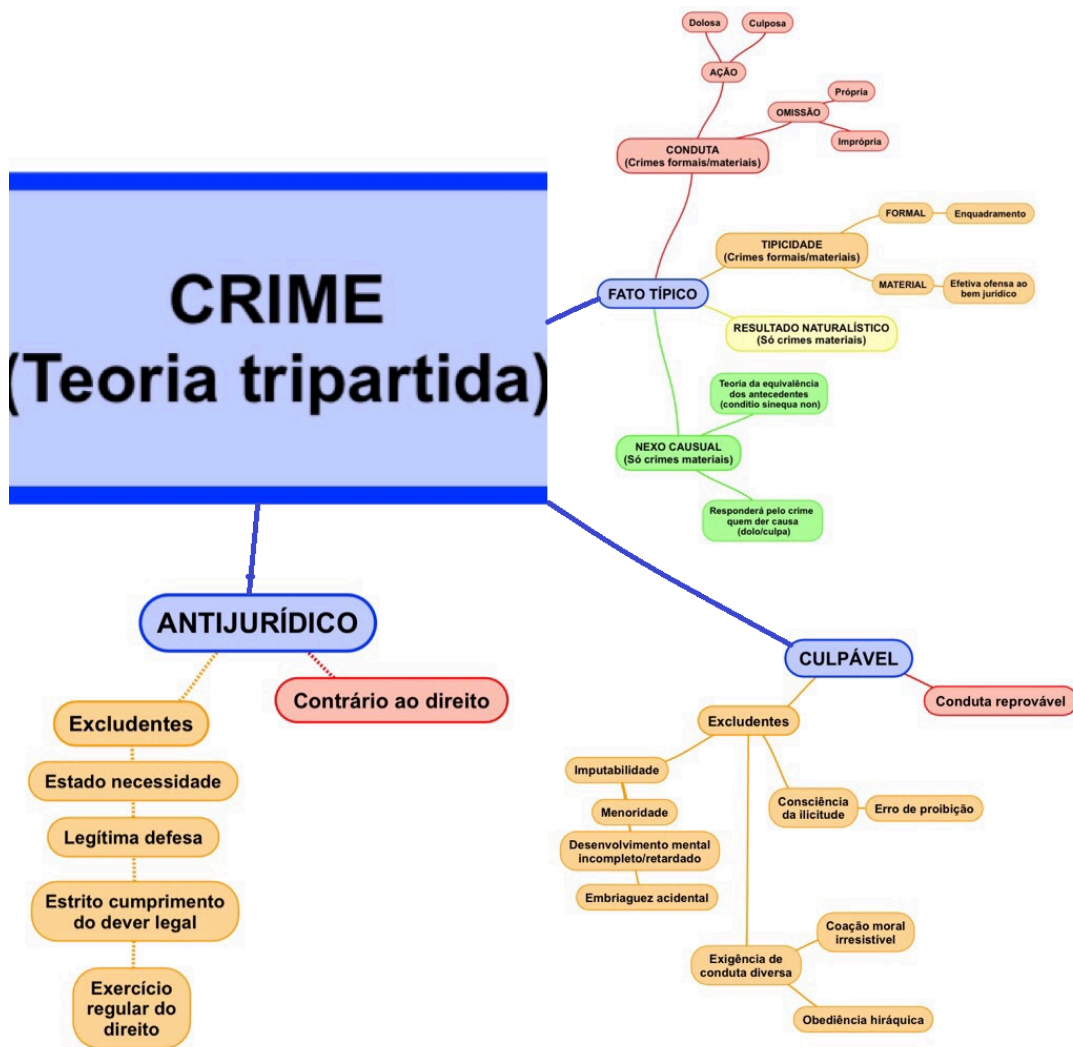
Art. 21 - O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço. Parágrafo único - Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência.

A culpabilidade também é afastada se não for possível exigir uma conduta diversa do agente. É o que ocorre na Coação Moral Irresistível e na Obediência Hierárquica. Veja o respectivo dispositivo do Código Penal:

Art. 22 - ***Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem.***

Como dito, veremos isso detalhadamente em aula própria. Por enquanto, quero que você tenha noção do TODO. Passar pelas avenidas antes de entrar nas ruas.

Vamos fazer um resumo de CRIME.



Estude novamente essa aula.

É muito importante.

Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO

Essa PALAVRA vale mais que sua aprovação:

"Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus." Romanos 3:23

"Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados" Atos 3:19

"Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna". João 3:16

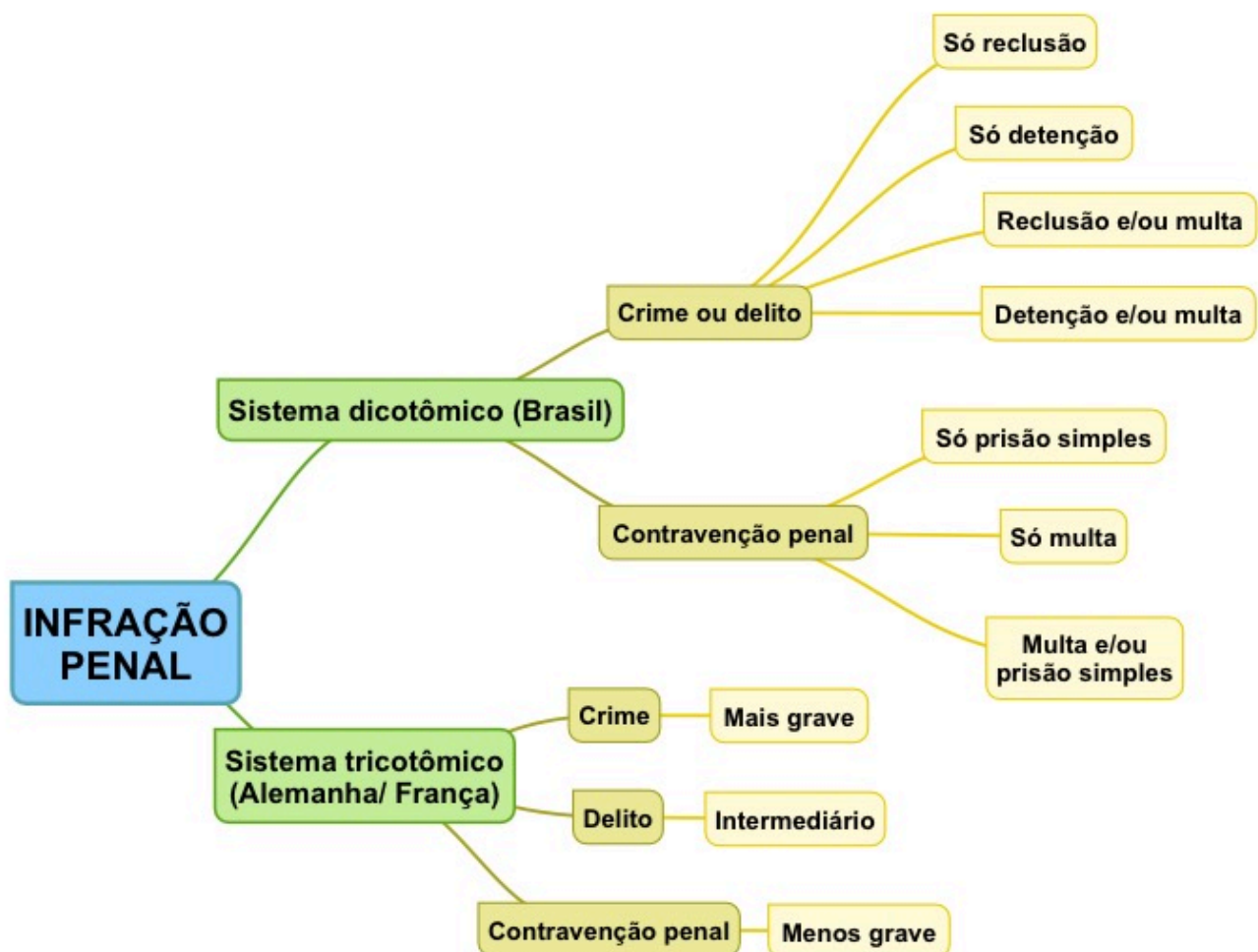
“Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo.” Romanos 10:9

Resumo

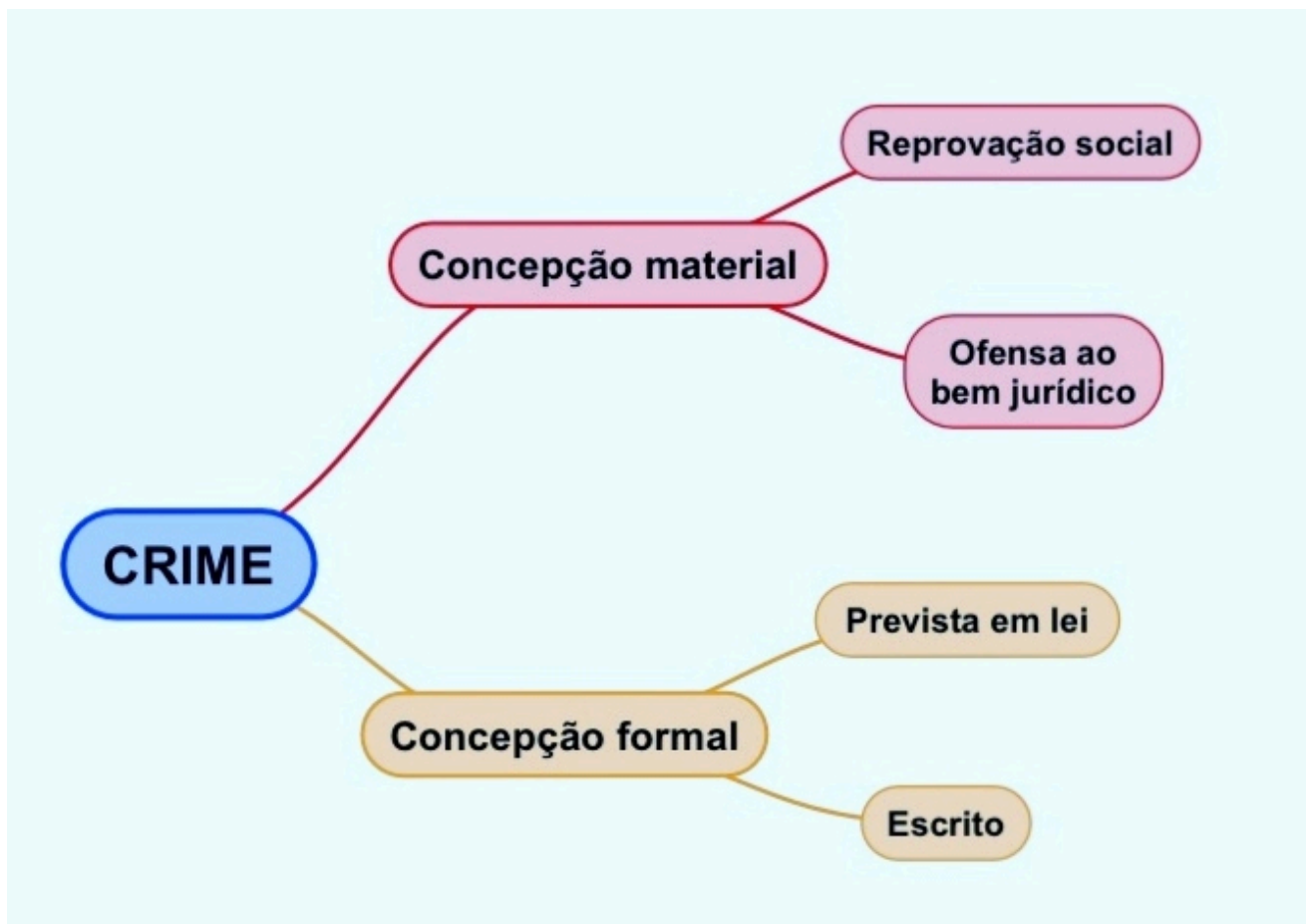
CONCEITO DE CRIME

1. INFRAÇÃO PENAL: CRIME E CONTRAÇÃO PENAL

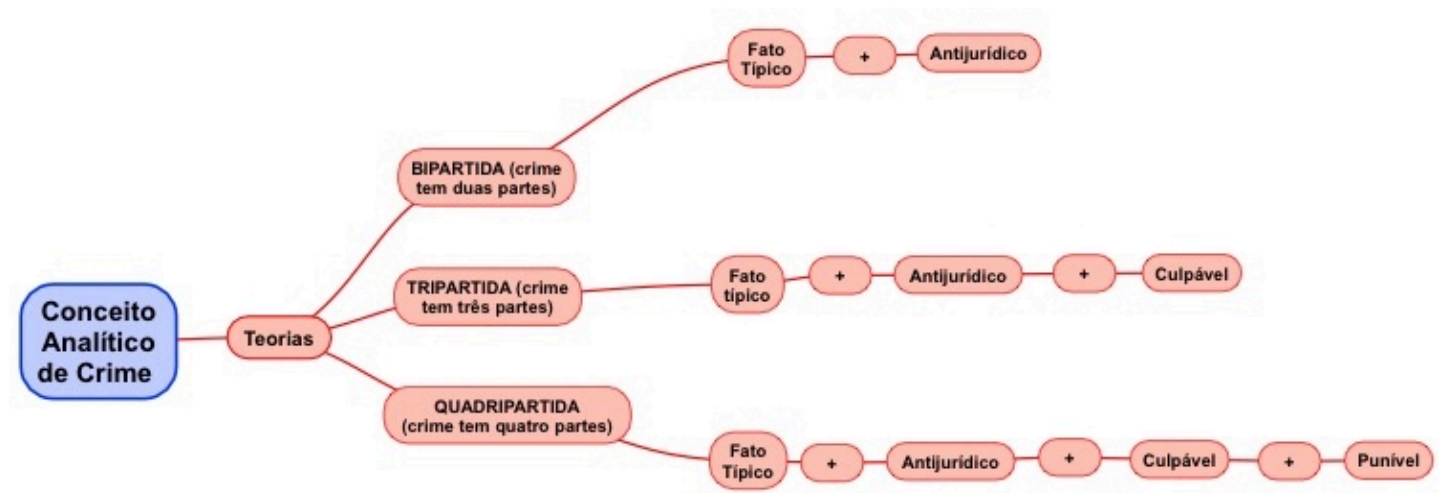
Lei de Introdução ao Código Penal Art 1º Considera-se **crime** a infração penal que **a lei comina pena de reclusão ou de detenção**, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa; **contravenção**, a infração penal a que a lei comina, **isoladamente, pena de prisão simples ou de multa**, ou ambas, alternativa ou cumulativamente.



2. CONCEITO MATERIAL E FORMAL DE CRIME



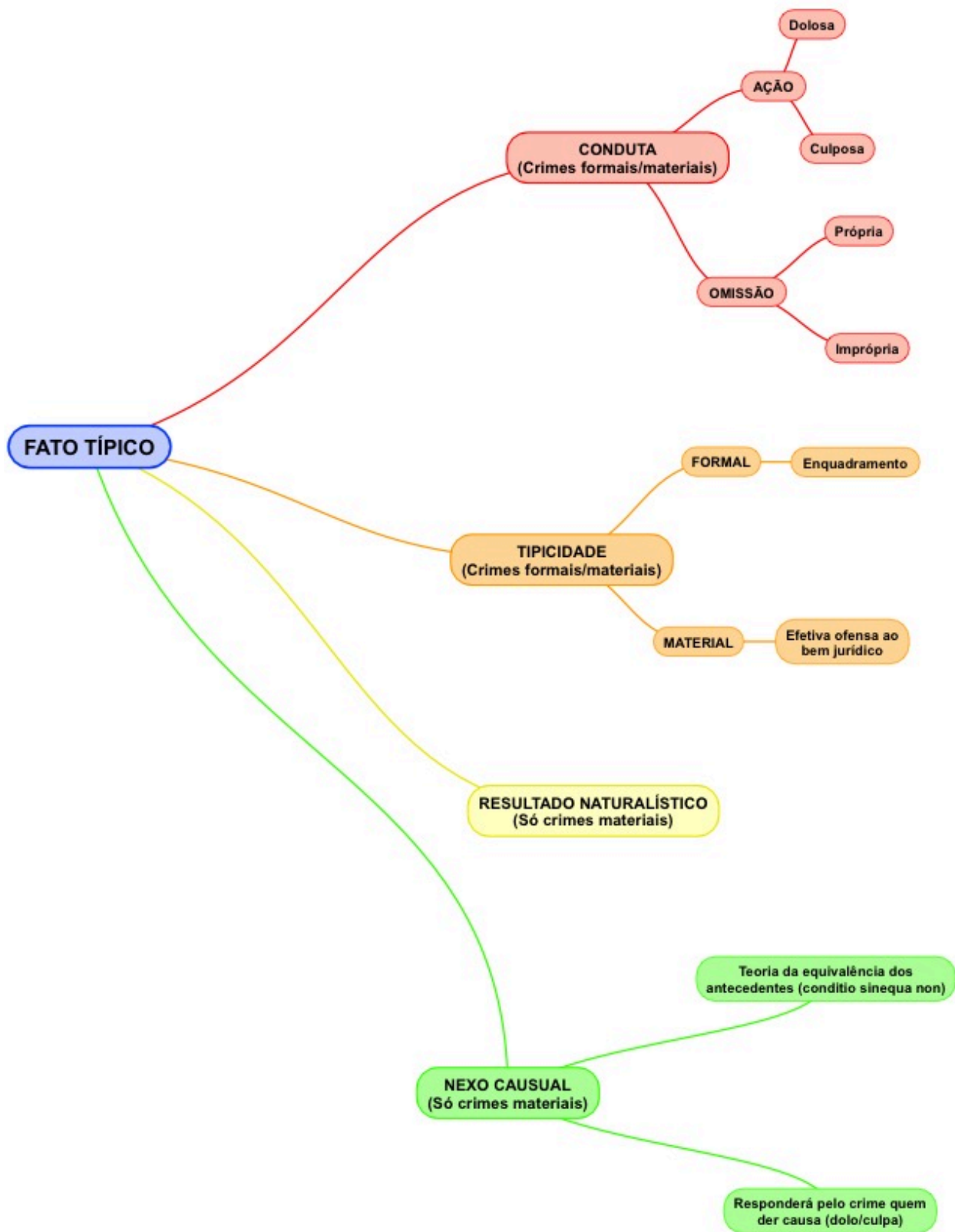
3. CONCEITO ANALÍTICO DE CRIME



4 PARA SER CRIME O FATO DEVE SER TÍPICO

Código Penal:

Art. 18 – Diz-se o crime: I - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo; II - culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. **Relação de causalidade** Art. 13 - O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. **Superveniência de causa independente** § 1º - A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado; os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou **Relevância da omissão** § 2º - A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem: a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado; c) com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado.



5 PARA SER CRIME O FATO TÍPICO DEVE SER ANTIJURÍDICO

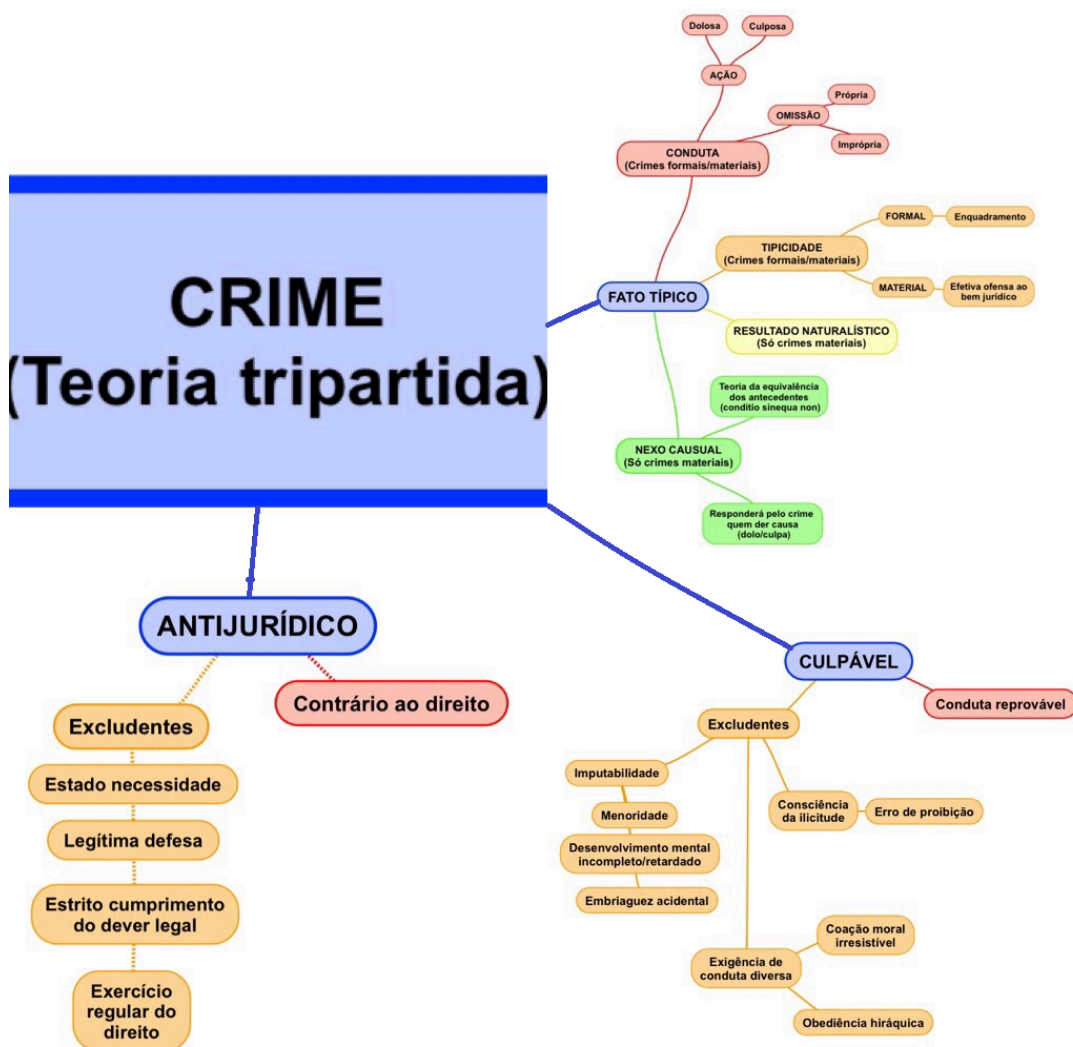
Código Penal:

Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato: I - em estado de necessidade; II - em legítima defesa; III - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Parágrafo único - O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposos.

6 PARA SER CRIME O FATO TÍPICO ILÍCITO DEVE SER CULPÁVEL (teoria tripartida)

Código Penal:

Art. 27 - **Os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente inimputáveis**, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Art. 26 - **É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento**. Art. 28 (...) § 1º - **É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento**. Art. 21 - O desconhecimento da lei é inescusável. **O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço**. Parágrafo único - Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. Art. 22 - **Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem**.



Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
